

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5085821-72.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 33ª VF DO RIO DE JANEIRO

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO QUANTO À ABRANGÊNCIA DA COISA JULGADA FORMADA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. CONDENAÇÃO QUE NÃO ABRANGE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUANTO À IMPLANTAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO POIS A COISA JULGADA DETERMINA SEU PAGAMENTO APENAS DURANTE O LABOR PERMANENTE COM PACIENTES COM COVID. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **CONCEDER A SEGURANÇA** requerida nestes autos. Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Notifique-se o Juízo impetrado. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2024.

5085821-72.2024.4.02.5101

510014874671 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5085821-72.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 33ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela União contra decisão proferida pelo Juízo Substituto da 33ª VF do Rio de Janeiro no **evento 107 dos autos nº 5002141-63.2022.4.02.5101** nos seguintes termos:

"Foi determinado à União a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer, bem como a juntada aos autos de planilha informando o montante devido à parte autora.

No caso, pela União foi juntado cálculo no Evento 85, OFIC2, Página 5 computando-se os meses de outubro de 2022 a junho de 2023 com adicional de insalubridade em valor equivalente a 10% sobre o vencimento básico.

Após a impugnação da parte exequente, no Evento 92 foi reconhecido pelo Juízo que a executada não implantou o adicional de insalubridade no grau máximo, nos termos do acórdão proferido no Evento 66.

Intimada para cumprir a obrigação de atualizar a remuneração da exequente com 20% sobre o vencimento básico, a União alegou no Evento 103 que "o acórdão acolheu apenas a obrigação de pagar o adicional em grau máximo durante o período da pandemia, não havendo obrigação de fazer".

Contudo, na verdade, o título executivo não limitou o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo durante o período de pandemia de Covid - 19, ou seja, durante o período de 20 de março de 2020 (com base no Decreto Legislativo nº 06 de

março de 2020) até 20 de junho de 2022 (Decreto nº 11.077/2022).

Até porque, no Voto, houve limitação do pagamento dos atrasados a contar da data de assinatura do Laudo Pericial em 14/10/2022 (Evento 34).

Foi dado provimento ao recurso da União para para que o adicional de insalubridade em grau máximo seja pago apenas enquanto perdurar o labor nas condições apontadas no voto.

Transcrevo a fundamentação do Voto, anexado no Evento 66, RELVOTO1, Páginas 10/11, com grifos nossos:

"No caso EM EXAME, as condições de trabalho da parte recorrida estão comprovadas pela perícia judicial realizada no próprio ambiente de trabalho (Hospital Federal Cardoso Fontes: Av. Menezes Cortes, 3245 - Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ.) e também pela verificação das atividades de servidor auxiliar de enfermagem, tendo o perito do Juízo confirmado (Evento 34, laudo 1, folha 9), que o servidor labora em contato com doenças infectocontagiosas e mais especificadamente com doentes por COVID-19

"(...) Diante das atividades desempenhadas pela parte Autora, relatadas no presente Laudo Pericial, as mesmas são realizadas em uma área de risco biológico que ainda assim a exposição se apresenta durante a sua jornada de trabalho e de forma habitual e permanente. Ainda assim a parte autora durante a sua jornada de trabalho está sujeita a Doenças infectocontagiosas como Tuberculose, Meningite, HH1N1, Marsa, KPC, HIV, Hepatite, Covid, VRE entre outras. (...)..."

Portanto, restou comprovado que a parte autora laborou em setor em contato permanente com pacientes portadores da COVID, sendo esta doença infectocontagiosa e que demanda isolamento obrigatório.

Logo, a hipótese fática e a prova específica destes autos demonstram a necessária aplicação da NR-15 para fins de conferir o percentual máximo do adicional. Portanto, a sentença está correta no que diz respeito à condenação do réu ao pagamento do adicional de insalubridade em percentual máximo.

Entretanto, na forma do entendimento atual desta Turma Recursal, tal pagamento deverá ser limitado ao período de efetiva exposição aos pacientes portadores da COVID, e se manterá o pagamento no grau máximo apenas enquanto a parte autora estiver em exposição à referida doença, assim merece parcial provimento o recurso da União.

No que tange aos efeitos financeiros, esta 8ª Turma Recursal possuía entendimento pela distinção em relação ao PUIL 413 do E. STJ, quando o servidor público atuasse em período anterior ao reconhecido no laudo, com exposição aos agentes nocivos, uma vez que a gratificação de Raio X e a irradiação ionizante tem por fundamento a exposição ao mesmo agente nocivo, contudo, considerando que a TNU não tem aceitado tal distinguishing e determina o retorno dos processos para retração da decisão da Turma, passo a adotar os Termos do PUIL 413 e o efeitos financeiros devem ser fixados a partir do laudo pericial (14/10/2022)."

Tanto a Planilha apresentada pela União no Evento 85, OFIC2, Página 5, quanto à Planilha juntada pela autora no Evento 105, PLAN3, Páginas 1/2 foram elaboradas com data de início dos atrasados em dissonância com o título judicial, e, portanto, não podem ser adotadas para pagamento.

Por outro lado, em relação à data de término dos atrasados, o Demonstrativo de Rendimento Anual de 2014 (Evento 97, FINANC4) leva à conclusão de que não foi cumprida pela União a obrigação de fazer, pelo menos até abril do mesmo ano, pois nesse mês o adicional de insalubridade foi pago em valor equivalente a 10% sobre o vencimento básico, em contrariedade com o título judicial com determinação para ser pago 20%.

Então, para a elaboração da conta será necessário saber o mês em que foi iniciado o pagamento de adicional em grau máximo, com o objetivo de limitar o cálculo até o mês anterior.

Decido.

Tendo em vista que já foi determinado no Evento 76, com prazo de 60 (sessenta) dias e reiterado nos Eventos 82, 92 e 100, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento, **intime-se a União para que comprove o cumprimento da obrigação de implantar o pagamento de Adicional de Insalubridade de 20%**

sobre o vencimento básico, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de aplicação diária majorada para R\$ 100,00 (cem reais) por dia, limitada a R\$ 3.000,00 (três mil reais), na esteira do disposto no art. 537, § 1º, do CPC.

Atendido, intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a planilha com os valores devidos, caso haja possibilidade.

Importante frisar que a planilha informando o montante devido à parte exequente, deverá considerar as quantias recebidas pelo pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, conter cálculo dos valores efetivamente devidos a título de PSS, devendo o percentual de 11% incidir sobre a parcela devida, sem juros ou correção monetária, com termo inicial a contar do laudo pericial e termo final até o mês anterior ao início dos pagamento de adicional em grau máximo em contracheque, e ainda observando-se a correção monetária e juros, conforme dispositivo da sentença (Evento 51):

"Os valores pretéritos devem sofrer a incidência do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 na redação dada pela Lei nº 11.960/09, no que se refere a juros e correção monetária, de modo que seja aplicada a TR (índice da caderneta de poupança) até 25/03/2015, passando, a partir de então, a correção monetária a correr pelo IPCA-E (conforme a modulação dos efeitos da ADIn 4.357/DF) e os juros de mora pelo índice da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97)."

Apresentada a planilha de cálculos, dê-se vista à União para manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535 do CPC.

Caso não haja impugnações, prossiga-se com a execução."

Narra a União, em síntese, que a ordem de implantação do adicional de insalubridade em grau máximo está em desconformidade com o título executivo judicial, visto que esse percentual seria devido apenas no período da pandemia de Covid-19, já encerrado. Alega que a decisão impetrada viola a coisa julgada e acarreta o enriquecimento sem causa do servidor. Pede a concessão da liminar a fim de suspender a execução até que se defina, nesta ação mandamental, se a obrigação de fazer imposta pelo Juízo de origem observa os limites fixados no acórdão.

O requerimento de liminar foi deferido por esta Relatora unicamente para o fim de suspender o curso do processo principal, até o julgamento final deste mandado de segurança.

O Juízo impetrado prestou informações adicionais.

A União - Fazenda Nacional não apresentou resposta.

O Ministério Público Federal não manifestou interesse em intervir no feito

É o breve relatório.

VOTO

Da análise das circunstâncias do caso concreto, entendo que a segurança requerida nesta demanda deve ser concedida, conforme razões a seguir expostas.

Com efeito, o pedido constante da petição inicial dos autos requer o pagamento unicamente do adicional de insalubridade em 20%:

"3 - o julgamento pela procedência do pedido para condenar a Ré ao pagamento IMEDIATO dos valores não pagos a título de insalubridade, bem como, seja implantado em seus vencimentos o percentual de 20% (vinte por cento) a título de adicional de insalubridade devidamente atualizados monetariamente na forma do enunciado nº 111 das TRRJ"

A sentença julga procedente o pedido no seguinte sentido:

Diante do exposto, na forma do art. 487, I, do CPC:

1) **JULGO PROCEDENTE** o pedido, para condenar a ré a implantar no contracheque da parte autora o adicional de insalubridade em grau máximo, equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico, nos termos da NR 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho;

2) **JULGO PROCEDENTE EM PARTE** o pedido, para condenar a ré a pagar à autora os valores atrasados, a partir de 14.10.2022, referentes ao adicional de insalubridade, equivalentes a 10 % (dez por cento) do vencimento básico nesse mesmo período, respeitado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Após recurso da União, a decisão colegiada entendeu que:

Em ambas as normas regulamentares acima, próprias para servidores federais, vê-se que o conceito de habitualidade e permanência trazido na primeira instrução transcrita vem mesmo confirmar que - tal como se dá com a NR 15 - a insalubridade máxima só deve ser remunerada por adicional correspondente quando demonstrado o trabalho habitual e permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas ou que demandem tal isolamento. (...)

No caso EM EXAME, as condições de trabalho da parte recorrida estão comprovadas pela perícia judicial realizada no próprio ambiente de trabalho (Hospital Federal Cardoso Fontes: Av. Menezes Cortes, 3245 - Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ) e também pela verificação das atividades de servidor auxiliar de enfermagem, tendo o perito do Juízo confirmado (Evento 34, laudo 1, folha 9), que o servidor labora em contato com doenças infectocontagiosas e mais especificadamente com doentes por COVID-19.

Confira-se (fl. 09 do laudo):

"(...) Diante das atividades desempenhadas pela parte Autora, relatadas no presente Laudo Pericial, as mesmas são realizadas em uma área de risco biológico que ainda assim a exposição se apresenta durante a sua jornada de trabalho e de forma habitual e permanente. Ainda assim a parte autora durante a sua jornada de trabalho está sujeita a Doenças infectocontagiosas como Tuberculose, Meningite, H1N1, Mersa, KPC, HIV, Hepatite, Covid, VRE entre outras. (...)".

Portanto, restou comprovado que a parte autora laborou em setor em contato permanente com pacientes portadores da COVID, sendo esta doença infectocontagiosa e que demanda isolamento obrigatório.

Logo, a hipótese fática e a prova específica destes autos demonstram a necessária aplicação da NR-15 para fins de conferir o percentual máximo do adicional. Portanto, a sentença está correta no que diz respeito à condenação do réu ao pagamento do adicional de insalubridade em percentual máximo.

Entretanto, na forma do entendimento atual desta Turma Recursal, tal pagamento deverá ser limitado ao período de efetiva exposição aos pacientes portadores da COVID, e se manterá o pagamento no grau máximo apenas enquanto a parte autora estiver em exposição à referida doença, assim merece parcial provimento o recurso da União.

No que tange aos efeitos financeiros, esta 8ª Turma Recursal possui entendimento pela distinção em relação ao PUIL 413 do E. STJ, quando o servidor público atuasse em período anterior ao reconhecido no laudo, com exposição aos agentes nocivos, uma vez que a gratificação de Raio X e a irradiação ionizante tem por fundamento a exposição ao mesmo agente nocivo, contudo, considerando que a TNU não tem aceitado tal *distinguishing* e determina o retorno dos processos para reatuação da decisão da Turma, passo a adotar os Termos do PUIL 413 e o efeitos financeiros devem ser fixados a partir do laudo pericial (14/10/2022).

Pelo exposto, **VOTO POR CONHECER DOS RECURSOS, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO** para que o adicional de insalubridade em grau máximo seja pago apenas enquanto perdurar o labor nas condições apontadas no voto. **NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA.** Sem custas e honorários. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem.

Ou seja, a insalubridade máxima - que é objeto do questionamento deste *mandamus* - foi estabelecida como devida apenas durante o período da pandemia de COVID. No entanto, adotando-se o PUIL 413 para a finalidade de pagamento de atrasados, se verifica que não haverá implantação do adicional máximo em contracheque já que a epidemia finalizou em junho de 2022 - 2 (Decreto nº 11.077/2022)".

Assim, como a obrigação de pagar a insalubridade maxima ficou estabelecida apenas durante o labor com pacientes infectados por COVID, de forma permanente, não há realmente obrigação de fazer quanto à implantação do adicional para insalubridade máxima. Há apenas a obrigação de pagar o adicional de insalubridade máxima durante o período da pandemia, com efeitos financeiros a partir do laudo pericial.

Pelo exposto, nos moldes da fundamentação, VOTO POR CONCEDER A SEGURANÇA requerida nestes autos. Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Notifique-se o Juízo impetrado. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.